

SYED SAHIB SHAH BIN KAKI MIAN

lwn

AINA DHOBITAH BINTI MD ISA

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 20 Oktober 2022 / 25 Rabiulawal 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-028-0052-2019

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak di bawah seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Encik Boestamam bin Ahmad
(Tetuan Boestamam Ahmad & Co.)*

Pegum Syarie Responden : *Puan Nor Hafizah binti Haron
(Tetuan Hafizah Haron & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 10/6/2019 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 29/5/2019 dalam kes Saman No. : 10200-028-0178-2018. Terma-terma perintah tersebut adalah seperti berikut :

- i. *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak bernama Sayyidah Sahibbah Humairah binti Syed Sahib Shah [No Mykid : 160824-10-0534] dan Sayyidah Aafiyah Humaira binti Syed Sahib Shah [No Mykid : 180611-10-0872] diberikan kepada Defendan selaku ibu kandung.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff sebagai bapa diberikan hak melawat anak-anak tersebut tanpa bermalam pada hari Ahad minggu pertama dan ketiga setiap bulan bermula jam 9.00 pagi hingga jam 5.00 petang.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan lokasi lawatan anak-anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak-anak tersebut.*

[2] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 25/1/2021 yang mengandungi tiga (4) alasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Rekod Rayuan. Selanjutnya Perayu telah memfailkan hujahan bertulisnya pada 30/3/2022 diikuti dengan hujahan Responden pada 29/4/22 dan hujahan balas Perayu pada 25/5/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 18/7/2022 yang lalu.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 14/8/2015 di Kuala Lipis, Pahang. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu :

- i. Sayyidah Sahibbah Humairah binti Syed Sahib Shah [No Mykid : 160824-10-0534]
- ii. Sayyidah Aafiyah Humaira binti Syed Sahib Shah [No Mykid : 180611-10-

[4] Pada 29/3/2018, Perayu telah memfailkan Tuntutan Hak Jagaan Anak (Hadhanah) yang pertama terhadap Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Semasa tuntutan dibuat, pihak-pihak masih berstatus suami isteri yang sah dan anak kedua belum dilahirkan. Perayu kemudiannya telah memfailkan Pernyataan Tuntutan Terpinda pada 12/7/2018 yang menuntut hak jagaan bagi kedua-dua anak.

[5] Perayu dan Responden kemudiannya telah sah bercerai dengan talak satu pada 3/5/2021 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat dalam kes Saman No: 10008-055-0756-2019 iaitu selepas hampir dua tahun perintah hak jagaan anak sebagaimana pada perenggan [1] dikeluarkan.

[6] Perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuannya dengan memplidkan empat Alasan Rayuan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu sedangkan Perayu dan Responden masih suami isteri yang sah.
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila langsung tidak mempertimbangkan peranan ahli keluarga Responden yang menghasut supaya Responden meninggalkan rumah kelamin dan membawa anak-anak tinggal berjauhan daripada Perayu.
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang

apabila tidak mempertimbangkan fakta bahawa Responden tidak memberikan kerjasama kepada Perayu dalam permohonan menyambung visa untuk tinggal di Malaysia menunjukkan *prima facie* niat Responden untuk memisahkan Perayu dengan anak-anak.

- iv. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya memberikan hak lawatan anak-anak kepada Perayu tanpa memberikan perintah lanjutan visa kepada Perayu bagi membolehkan Perayu melawat anak-anak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Berdasarkan pengamatan kami kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak, kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada SATU isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memerintahkan hak jagaan bagi kedua-dua anak kepada Responden selaku ibu kandung.**

[8] Melalui alasan penghakimannya, YA Hakim Bicara menyatakan semasa tuntutan hak jagaan difailkan, kedua-dua anak tersebut masih belum mumaiyiz. Justeru, berdasarkan pertimbangan peruntukan undang-undang dan hukum Syarak maka hak jagaan sewajarnya diberikan kepada Responden selaku ibu kandung. YA Hakim Bicara turut membuat dapatan bahawa Perayu gagal membuktikan bahawa Responden telah hilang kelayakan sebagai *hadrinah*.

[9] Berhubung dengan hak lawatan pula, YA Hakim Bicara berpandangan dengan mengambil kira umur anak-anak tersebut serta kebimbangan anak-anak tersebut

dilarikan sebagaimana insiden-insiden yang pernah berlaku sebelum ini selain tempoh visa Perayu untuk tinggal di negara ini bakal berakhir maka adalah sewajarnya Perayu diberikan hak lawatan tanpa bermalam. Jika anak-anak tersebut berjaya dibawa keluar dari negara ini akan menyebabkan kesukaran pelaksanaan perintah dan hak Responden untuk menjaga anak-anak tersebut hanya menjadi sia-sia.

[10] Perayu berhujah bahawa tuntutan hak jagaan anak yang difailkan oleh Perayu berpunca daripada niat Responden dan hasutan keluarganya untuk memisahkan anak-anak tersebut daripada Perayu yang mana pada ketika itu pihak-pihak masih lagi berstatus suami isteri. Hal ini berasaskan tindakan Responden yang tidak memberikan kerjasama kepada Perayu untuk sama-sama hadir ke Pejabat Imigresen bagi membuat permohonan menyambung visa menetap di Malaysia. Menurut Perayu, YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam penghakimannya.

[11] Responden pula menghujahkan tiada sebarang bukti kukuh yang dikemukakan oleh Perayu berhubung dengan hasutan yang didakwa dilakukan oleh keluarga Responden. Dalam masa yang sama Responden menyatakan Perayu masih lagi dapat berjumpa dengan anak-anak tersebut sebagaimana keterangan saksi Perayu sendiri. Fakta ini sekali gus menafikan dakwaan Perayu bahawa Responden dan keluarganya berusaha untuk memisahkan anak-anak tersebut daripada Perayu selaku bapa kandung.

[12] Berkenaan dengan permohonan Perayu untuk melanjutkan visa pula, Responden berhujah bahawa isu ini tidak relevan untuk dibangkitkan dalam tindakan ini. Alasan tersebut hanya digunakan oleh Perayu untuk memperalatkan Responden

dan anak-anak untuk kepentingan mendapat kebenaran bermastautin dan menetap di Malaysia dengan mudah. Menurut Responden juga, YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila telah mengambil kira status anak-anak tersebut yang belum mumaiyiz dalam membuat keputusan.

[13] Secara prinsipnya bagi menentukan hak jagaan anak yang masih belum mumaiyiz, kami dipandu oleh seksyen 82 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

[14] Peruntukan tersebut secara jelas menyatakan bahawa ibu adalah pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumaiyiz) dan hak ini diberikan kepada ibu apabila memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan seksyen 83 Enakmen yang menyatakan:

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—

- (a) dia adalah seorang Islam;*
- (b) dia adalah sempurna akal;*
- (c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;*
- (d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan*
- (e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.*

[15] Berdasarkan kedua-dua peruntukan ini dan telah menjadi prinsip yang mantap kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara yang bersandarkan kepada autoriti-autoriti Syarak bahawa hak jagaan kedua-dua anak yang belum mumaiyiz

sewajarnya diberikan kepada Responden selaku ibu kandung melainkan Responden dibuktikan telah hilang kelayakannya sebagai *hadhinah*. Namun begitu, melalui pemerhatian kami kepada setiap Alasan Rayuan Perayu, isu kelayakan dan kedudukan hak jagaan anak yang belum mumaiyiz ini tidak dbangkitkan. Oleh yang demikian pada hemat kami kelayakan Responden selaku *hadhinah* adalah tidak tergugat dan tiada keperluan untuk kami mengulas lanjut dapatan YA Hakim Bicara berkenaan isu-isu tersebut.

[16] Dari sudut status quo pula menunjukkan bahawa kedua-dua anak tersebut telah berada dalam jagaan Responden sejak lahir sehingga sekarang. Manakala Perayu pula seorang warganegara Pakistan yang telah diberikan akses untuk melawat anak-anak tersebut. Dari sudut kepentingan, Perayu tidak menunjukkan kepada kami sebarang keterangan berkenaan kebajikan anak-anak yang terjejas selama dalam jagaan Responden. Dalam hal ini kami merujuk kepada seksyen 87(3) yang memperuntukkan :

(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.

[17] Berasaskan fakta dan peruntukan tersebut, pada hemat kami adalah sesuatu yang tidak wajar untuk penjagaan sedia ada bertukar tangan bagi mengelakkan kemudaratannya dari sudut emosi dan mental kedua-dua anak tersebut yang kini berusia 4 dan 6 tahun yang masih dikategorikan belum mencapai umur mumaiyiz. Dapatan ini turut selari dengan prinsip "*saddu zara'ie*" (سد الزرائع) yang bermaksud

menghalang jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemudharatan dan bertepatan dengan kaedah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Kemudharatan hendaklah dielakkan seboleh mungkin.

[18] Bagi memperkukuhkan pandangan ini dengan hormatnya kami merujuk keputusan yang dibuat oleh Jemaah Pengadilan dalam kes *Wan Abdul Aziz lwn Siti Aishah (1975) 1 JH 47* yang berpendapat jiwa anak yang telah tinggal dan diasuh oleh nenek sebelah bapanya selama lebih kurang satu tahun akan tersentuh jika dipisahkan. Lebih-lebih lagi tidak ada keterangan yang menunjukkan kebajikan atau masalah kanak-kanak tersebut akan terjejas dalam pemeliharaan neneknya dan dijaga serta diawasi oleh bapanya.

[19] Berkaitan Alasan Rayuan kegagalan YA Hakim Bicara mengeluarkan perintah melanjutkan visa kepada Perayu bagi tujuan Perayu melawat anak-anak pula, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa Mahkamah Bicara tidak berbidangkuasa untuk mengeluarkan perintah sedemikian. Dalam konteks kes ini isu yang perlu diputuskan oleh YA Hakim Bicara adalah berkenaan penentuan hak jagaan anak sahaja sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 61(3)(b)(iii) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah—

(a)

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—

(i).....

(ii).....

(iii) nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;

[20] Sukacita untuk kami mengingatkan pihak-pihak bahawa hak jagaan atau hadanah adalah berkait rapat dengan kepentingan kanak-kanak sebagaimana kehendak seksyen 87(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[21] Oleh itu sekiranya terdapat sebarang pertentangan hak antara kedua ibu bapa atau mana-mana pihak yang berkepentingan, ianya bukanlah menjadi hak eksklusif kepada mana-mana pihak sebaliknya hak kanak-kanak mesti diutamakan dari yang lain. Berasaskan kepada dapatan ini, sebarang keputusan membabitkan kanak-kanak perlu melihat kepada apa yang paling mendatangkan kebaikan kepada kanak-kanak secara keseluruhan atau yang disebut sebagai prinsip kebajikan kanak-kanak (*the welfare of the child*) atau kepentingan terbaik kanak-kanak (*the best interests of the child*).

[22] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah bertindak betul apabila memberikan hak jagaan anak-anak tersebut kepada Responden. Mana-mana pihak yang terkesan akibat kegagalan melaksanakan perintah tersebut wajar mengambil tindakan melalui peruntukan undang-undang yang relevan sama ada melalui penguatkuasaan atau perubahan perintah hak jagaan. Bagi maksud tersebut kami tidak berhasrat untuk mengganggu keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal No.: 10200-028-0178-2018 bertarikh 29/5/2019 DIKEKALKAN.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;



.....
1. YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

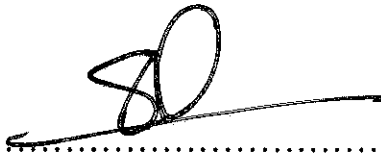
Dipersetujui oleh;

s.71 Enakmen Pentadbiran

.....
2. YAA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

